

1500104-93.2022.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: NAIRA BLANCO MACHADO

Comarca: Arujá

Foro: Foro de Arujá

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... qualquer outra prova que confirme a prática de tráfico de entorpecente, deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo em favor dos acusados.

Em sentido semelhante, manifesta-se a jurisprudência:

TÓXICO - Crime de tráfico e associação para o tráfico - Quadro probatório que não traz a necessária certeza quanto à posse ou propriedade da droga apreendida - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Arujá

Foro de Arujá

1ª Vara

Avenida Albino Rodrigues Neves, 394, Aruja - SP - cep 07400-000

1500104-93.2022.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500104-93.2022.8.26.0535

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

JORGE HENRIQUE VIEIRA MILARDE e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). NAIRA BLANCO MACHADO

Vistos.

MATHEUS DIAS MASSARO e JORGE HENRIQUE VIEIRA MILARDE, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pois, no dia 13 de janeiro de 2022, às 22:30 horas, na Rua Prefeito Júlio Barbosa de Souza nº 640, Mirante, Arujá/SP, os acusados, em unidade de desígnios e identidade de propósitos, traziam consigo, para fins de tráfico, 46 embalagens plásticas contendo cocaína e 25 porções de cocaína em forma de crack (massa líquida de 36,63g), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo a exordial acusatória, na data dos fatos, os acusados estavam no escadão da Serra da Loá, conhecido ponto de venda de drogas. No local, Jorge trazia consigo uma sacola contendo 46 porções de cocaína e 25 porções de crack, enquanto Matheus manuseava o dinheiro obtido com o comércio das drogas.

Ocorre que policiais receberam notícia acerca do tráfico de drogas no local e decidiram fazer patrulhamento a pé, chegando pela parte superior do escadão, momento em que visualizaram os acusados realizando a contabilidade do tráfico. Jorge fugiu do local, mas acabou sendo abordado. Durante revista, foram encontradas as drogas acima mencionadas, as quais estavam na sacola que Jorge trazia consigo. Matheus também foi abordado pela polícia, oportunidade em que foram localizados seis celulares e a quantia de R\$ 144,00 (cento e quarenta e quatro reais). Ainda,

no momento da abordagem, Matheus quebrou um dos celulares com as próprias mãos, batendo contra o joelho (fls. 79/82).

Auto de prisão em flagrante (fls. 04). Boletim de ocorrência (fls. 02/03). Auto de exibição e apreensão (fls. 12/13). Laudo químico-toxicológico (fls. 14/18 e 171/173). Folha de antecedentes (fls. 50/58 e 187/193).

Em audiência de custódia foi convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 63/66).

Os réus foram notificados e apresentaram defesa preliminar (fls. 124/128 e 196).

Foi recebida a denúncia em 18 de maio de 2022 (fls. 163/164).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas e interrogados os réus ao final (fls. 227/232), sendo concedida liberdade provisória aos réus (fls. 227/228), com cumprimento do alvará de soltura em 10/08/2022 (fls. 249 e 252).

O Ministério Público apresentou alegações finais orais em audiência, postulando pela absolvição dos réus, porque malgrado a versão dos policiais militares no sentido de que abordaram os réus na posse de drogas, as testemunhas de defesa dão conta que as circunstâncias da prisão foram completamente diversas daquelas narradas pelos policiais. Destacou a inconsistência no depoimento dos policiais, sobretudo no tocante a Matheus, que não teria corrido apesar da presença policial, denotando que ele realmente não tinha envolvimento com o tráfico de drogas.

Arrematou que o conjunto probatório é frágil e não autoriza o decreto condenatório. A defesa do réu Matheus, em alegações finais orais, requereu a absolvição dos réus, por falta de prova da materialidade e autoria delitiva. Afirmou que os depoimentos dos policiais isolados não são capazes de demonstrar os fatos narrados na peça acusatória. Aduziu que inúmeros são os flagrantes que a mesma equipe de policiais realizaram na comarca de forma ilícita.

A defesa do réu Jorge, em alegações finais orais, afirmou que acompanha o entendimento do Ministério Público pela absolvição dos réus, ante a inconsistência do depoimento dos policiais e pelo conteúdo probatório raso.

Vieram-me os autos conclusos para sentença.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Os autos estão em ordem. Não há preliminar a ser apreciada ou nulidade a ser declarada. Logo, o feito está apto a ser julgado.

A materialidade está demonstrada conforme boletim de ocorrência, laudo de constatação e prova oral colhida.

A autoria, por sua vez, não restou satisfatoriamente comprovada.

Passo à análise da prova oral.

A testemunha Willian, policial militar, relatou que em patrulhamento recebeu denuncia de 190 de tráfico no local, deslocando-se com seu companheiro. Aduziu que é uma viela onde há uma escadaria onde os indivíduos rotineiramente ficavam vendendo drogas. Acrescentou que desembarcou da viatura e fez a incursão a pé, pediu para que seu companheiro desse a volta com a viatura. Contou que manteve contato com seu parceiro e informou que tinha visualizado dois indivíduos na escada aparentemente fazendo a contabilidade, o Jorge segurava a sacola e Matheus contava dinheiro. Falou que deu o sinal para que seu companheiro avançasse e desceu correndo o escadão. Disse que o Jorge estava em pé com a sacola, quando ele viu o depoente descendo o escadão ele tentou correr também, o Matheus estava sentado e não esboçou reação. Mencionou que o Jorge viu a viatura fechando a outra ponta do escadão e entrou no outro terreno que tem ao lado, conseguindo detê-lo, e seu companheiro segurou o Matheus. Comentou que Jorge não soltou a sacola em nenhum momento e nela verificou os entorpecentes. Aduziu que o Matheus estava com o dinheiro nas mãos e mais seis aparelhos celulares. Externou que indagados a respeito ambos confessaram e falaram que os aparelhos celulares era de usuários que deixavam como garantia para depois voltar e pagar os entorpecentes que haviam pego. Salientou que o Matheus estava sentado, como foi pego de surpresa ele não conseguiu esboçar reação. Informou que abordou o Jorge e seu companheiro abordou o Matheus. Explicou que seu companheiro foi o que fechou pelo outro lado. Noticiou que haviam 46 eppendorfs e 20 pedras de crack. Salientou que haviam somente os dois no escadão. Esclareceu que não fez a abordagem do Matheus, quando chegou seu parceiro

já estava com os celulares na mão.

A testemunha José Nilton, policial militar, disse que foi uma denúncia via Copom 190, o depoente e seu parceiro armaram uma estratégia para surpreender os indivíduos porque o local já é conhecido como ponto de tráfico de drogas. Detalhou que seu parceiro desembarcou da viatura e ficou na rua de cima enquanto o depoente deu a volta com a viatura e desceu fechando o escadão. Afirmou que um foi por cima e outro foi por baixo, tinham dois indivíduos no meio do escadão, um segurava uma sacola e o outro não deu para ver o que segurava. Afirmou que o rapaz que estava segurando a sacola correu para um terreno lateral e seu parceiro foi atrás dele, e o depoente subiu o escadão e surpreendeu o Matheus. Informou que em revista ao Matheus encontrou seis celulares e R\$ 144,00 em notas miúdas. Aduziu que quando se aproximou o Matheus quebrou um dos celulares, não sabe por qual motivo. Apontou que seu parceiro pegou o outro indivíduo que trazia a sacola com entorpecentes, houve resistência por parte do Jorge. Falou que diante dos fatos foi dada voz de prisão, lidos os direitos constitucionais e encaminhada a autoridade de plantão. Mencionou que o Matheus não correu, ele permaneceu sentado no escadão. Frisou que tinha somente os dois no local. Disse que não encontraram petrechos ou anotações, foi somente a sacola com entorpecentes, os celulares e o dinheiro. Observou que os cinco celulares estavam no bolso, só tinha um na mão que ele quebrou. Revelou que a abordagem ocorreu a noite, não sabe precisar o horário, foi entre 21h e 22h. Destacou que só o Jorge confessou e falou que não era para prender ele porque já tinha passagem. Apontou que quem abordou o Jorge foi o William, ele foi encontrado num terreno do lado.

A testemunha Ricardo explanou que no terreno não tem muro e quando os policiais chegaram invadiram por baixo e por cima. Aduziu que os rapazes estavam todos ali bebendo e conversando, só viu aquele tumulto, inclusive estavam o depoente e seu irmão sentados na escada, os policiais os chamaram para ir para cima, mas responderam que não iriam porque estavam dentro de seu território. Externou que eles abordaram os dois, deitaram o Matheus e deram um mata leão nele, pegaram o celular e quebraram na cara dele. Destacou que não viu os policiais encontrarem droga. Disse lembrar apenas daquele momento, pois os policiais foram abordando eles, já entraram dentro da casa deles. Comentou que eles entraram no terreno, uns pegaram o Matheus e outros pegaram o Jorge e levaram para o outro lado. Frisou que não viu os policiais mostrando droga. Apontou que as casas ficam no mesmo terreno, o Matheus mora na casa de cima e o depoente mora na casa de baixo, só que não tem muro. Asseverou que no momento da abordagem eles estavam no terreno do Matheus. Acrescentou que conhece o Matheus como trabalhador, ele trabalha de pedreiro, inclusive vê ele saindo todo dia de manhã e voltando 17h da tarde. Repetiu que eles não estavam no escadão, mas no terreno do Matheus. Externou que eles não seguravam sacola, eles estavam tomando cerveja e com copo na mão.

A testemunha Regiane relatou que estava presente no dia, eles não estavam traficando, estavam em seu quintal. Revelou que é esposa do Matheus, estavam bebendo no dia, como de costume nos finais de semana se reúnem com os amigos. Falou que de repente começou a aparecer um monte de policial, eles falaram que tinha denuncia de tráfico de drogas, mas falaram que em seu quintal era casa de família e não tinha nada a ver com tráfico. Contou que mesmo assim eles entraram e já foram invadindo, disseram que achando ou não a droga iam levá-los, a depoente o Jorge e o Matheus. Complementou que levaram o Jorge para dentro da cozinha e o Matheus para o quintal. Pontuou que o William tirou uma sacola de dentro do bolso e falou que não achou a droga mas que ele tinha para levar.

O réu Matheus disse que tem 28 anos, é pedreiro, ganhava R\$ 150,00 por dia, é amasiado e tem quatro filhos, estudou até a oitava série, não foi processado antes. Relatou que no dia estava em sua casa bebendo com os amigos, num dia normal, uma quinta-feira, por volta de 20h, do nada a polícia apareceu. Explanou que estava deitado no quintal, onde tem um sofá e uma poltrona, estava com o Jorge, bebendo e fumando narguilé. Contou que viu uma viatura descendo a rua, até então normal, então viu a viatura parando e descendo um policial que subiu o escadão. Mencionou que na casa só tem muro até a metade do terreno, a outra metade não tem muro. Prosseguiu afirmando que viu o policial William descendo o escadão e vindo até sua

casa, ele abordou o depoente, sua esposa e o Jorge, já veio xingando, falando palavrão, mandando abaixar e por a mão na cabeça, dizendo que sabia que ali era ponto de tráfico. Complementou que estava em sua casa, onde tem cinco crianças dentro, seu enteado de 17 anos, então disse ao policial que ali não era ponto de drogas, que era casa de pai de família. Aduziu que o policial disse que não queria saber de nada, mandou por a mão na cabeça e deitar, mas o depoente respondeu que o chão era de terra e não tinha como deitar, então ele falou para sentar em cima da mão, o depoente obedeceu. Acrescentou que quando o William chegou perto o parceiro dele veio na sequência, ficando o parceiro com o depoente e o William pegou o Jorge e levou até a porta da casa, ficaram fazendo perguntas. Informou que o policial mandou desbloquear o celular, mas o depoente falou que não ia desbloquear porque tinha umas coisas íntimas suas com sua mulher e respondeu que não tinha motivo para desbloquear o celular porque já tinham entrado em sua casa xingando e falando palavrão na frente dos seus filhos. Externou que o policial rebatendo falando que ia desbloquear o celular sim, mas o réu insistiu falando que estava todo prepotente e ignorante, então o policial pegou o celular, o quebrou em sua cara, jogou em seu peito e falou para algemá-lo porque iriam levá-lo também. Afirmou que questionou por qual motivo iriam levá-lo, mas o policial lhe deu um mata leão, desmaiou e ficou desacordado, quando acordou já estava algemado. Aduziu que o policial falou para colocarem o depoente e Jorge na viatura, quando chegaram na viatura o policial sacou do bolso uma sacola branca, ele estava com os celulares do depoente, de sua esposa e de suas meninas, mas tinha mais celulares e colocou tudo dentro da sacola. Pontou que falaram que iriam levá-lo porque não quis desbloquear o celular, mas na delegacia apresentaram droga falando que era sua e que tinha que assumir a droga, mas o depoente se negou a assumir porque tinha acabado de chegar do serviço e nunca mexer com droga nenhuma. Noticiou que tinha R\$ 50,00 consigo e em cima da geladeira tinha R\$ 44,00 que é o dinheiro da passagem que deixa para ir usando durante a semana. Arrematou que a narrativa dos policiais é mentirosa, pois falaram que o pegaram no escadão, só que se o policial de fato passou pelo depoente correndo para pegar o Jorge e o parceiro dele veio subindo quem ficaria atrás do depoente para impedi-lo de sair correndo. Complementou que não precisa vender droga porque é trabalhador, tinha renda mensal boa, é o único que trabalha em casa e sustenta sua família, já trabalhou em vários condomínios de Arujá. Destacou que como mora perto do escadão há cinco anos sabe que na rua de cima tem ponto de drogas, tanto que já denunciou, e sabendo que ali é ponto de drogas iria ficar ali para que. Frisou que chegou do serviço, foi o tempo do Jorge chegar e ficarem bebendo ali. Revelou que os policiais entraram sem pedir, reviraram sua casa, o xingaram, lhe bateram na frente dos filhos, mesmo nunca tendo mexido com nada de errado, causando trauma em seus filhos.

O réu Jorge disse que tem 26 anos, trabalhava como camelô autônomo no Tatuapé, ganhava R\$ 2.000,00, estudou até o segundo ano, é amasiado e tem dois filhos, já foi processado por tráfico. Contou que no dia trabalhou das 05h até 16h no Tatuapé, a tarde ligou para o Matheus porque não estava muito bem psicologicamente, tinha uns dias que estava livre da cocaína, o Matheus lhe dava conselhos, ele é um rapaz bom, não usa drogas e é trabalhador. Falou que o chamou para tomar uma cerveja, chegou na casa dela umas 20h, ficou lá uns 15 minutos no quintal e a polícia chegou. Aduziu que a polícia chegou e falaram para ir até o escadão, mas disseram que não iriam porque estavam no quintal do Matheus e era terreno particular. Observou que os policiais entraram, abordaram o depoente, o Matheus, a Regiane e o Wellington. Rememorou que uns dias antes, um mês depois de ter saído da cadeia, estava em sua casa fumando um cigarro de maconha e o policial William o abordou e disse que iria forjar e matar, mas chamou sua mãe e irmã e eles saíram, mas disseram que se o pegassem sozinho iria fazer alguma coisa. Comentou que sua mãe até falou para denunciar o William porque ele estava ameaçando. Falou que os policiais apareceram e abordaram, estava com um cigarro de maconha, o policial pisou no chão e esbagaçou, passou seu RG, ele puxou e falou que ia levar para a delegacia para averiguação. Externou que o Matheus estava com o celular dele, ele pediu para desbloquear, mas o Matheus falou que não ia desbloquear porque tinha coisa pessoal, aí o policial pegou o celular e quebrou na cara dele, deu um mata

leão nele, desmaiou o Matheus e deu uma joelhada no estomago do depoente. Comentou que bateu só onde não dá hematoma, não ficou marca no rosto do Matheus, mas chegou a quebrar o celular. Ressaltou que invadiram e reviraram a casa inteira do Matheus, o terreno inteiro, não acharam nada além do cigarro do depoente. Comentou que quando os levaram para a viatura viu o policial tirando uma sacola do bolso, ao chegar na delegacia apresentaram as drogas lá. Complementou que sua esposa veio visitá-lo recentemente e contou que um casal de amigos foi abordado, o mesmo policial bateu no rapaz e falou que ia forjá-lo e até assediou a moça. Complementou que também encontraram com o depoente sua chave, isqueiro e R\$ 50,00. Arrematou que nunca precisou roubar ou traficar e nem gosta de ladrão.

Essa foi a prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Pela prova colhida nos autos, não há certeza de que os réus possuíam drogas para fins de tráfico e nem mesmo que a abordagem foi realizada nos moldes relatados pelas testemunhas policiais, tanto assim o é que o próprio Órgão Ministerial requereu a absolvição dos réus em suas alegações finais.

Os exames toxicológicos confirmaram a natureza entorpecente das drogas, sendo constatado que se tratava de cocaína.

Em seus interrogatórios, como se pode observar, os réus negaram a prática do delito de tráfico, alegando que estavam no local apenas bebendo e conversando, quando vieram a ser abordados pelos policiais, sendo confirmada a sua versão pelos depoimentos das testemunhas Ricardo e Regiane.

Em seus relatos os réus afirmaram que estavam na casa de Matheus quando os policiais apareceram, realizaram a abordagem de forma truculenta, encontraram apenas um cigarro de maconha com Jorge e demandaram o desbloqueio do celular de Matheus, após revirarem o imóvel, levaram os réus até a delegacia onde lhes atribuíram a propriedade de drogas que os réus disseram desconhecer.

Ressalte-se que o depoimento prestado pelos réus em solo policial é muito semelhante àquele apresentado em Juízo, com quase nenhuma ou poucas dissensões (fls. 07/08), sendo naquela ocasião atribuída a responsabilidade das drogas ao policiais.

Como se pode observar, o relato dos réus é, no mínimo, incomum, sendo feitas imputações graves concernentes à conduta dos policiais que efetuaram a abordagem, com menção a diversas ações que destoam da regra de comportamento legal condizente com o cargo ocupado pelos agentes da lei.

Ainda, os relatos dos réus terminaram sendo reforçados pelas versões das testemunhas trazidas a depor, logrando êxito a defesa em produzir elementos probatórios idôneos capazes de captar o convencimento do magistrado, fazendo frente às provas produzidas pelo órgão acusador, influenciando de forma decisiva no julgamento.

Os policiais apresentaram singela narrativa dos fatos, limitando-se a afirmar que após o recebimento de denúncias sobre prática de comércio espúrio se dirigiram até o local dos fatos, um escadão, onde abordaram os acusados. Disseram que localizaram drogas em poder do acusado Jorge e dinheiro e seis aparelhos celulares em poder do acusado Matheus.

Quando indagados em Juízo pelas defesas os policiais negaram que teriam o intuito escuso de prejudicar os réus gratuitamente. Contudo, não passa despercebido que em seu relato, o réu Jorge apontou que teria sofrido perseguição pretérita por parte do policial William, que o ameaçou anteriormente de forjar provar objetivando aprisioná-lo.

E fato é que analisando detidamente o contexto probatório dos autos constata-se inúmeros conflitos entre as versões colhidas, em especial entre aquelas dos réus e testemunhas com a palavra isolada dos policiais.

Os milicianos afirmaram que abordaram os réus num escadão, ao passo que os réus e testemunhas relataram que a abordagem se deu na residência de Matheus. Ainda, os policiais afirmaram que encontraram uma sacola de drogas com Jorge, contudo as testemunhas disseram que não visualizaram a apreensão de drogas e os réus disseram que tais drogas não lhes pertenciam e somente foram apresentadas pelos policiais na delegacia. Outrossim, os agentes da lei apontaram a apreensão de seis aparelhos celulares com Matheus, dizendo que teriam sido entregues por usuários como garantia

de dívidas, no entanto os réus disseram que os celulares eram de Matheus, de sua esposa e de suas filhas. Além disso, os policiais afirmaram que Matheus teria quebrado seu próprio celular, tendo este afirmado, por sua vez, que se negou a desbloquear o aparelho em razão de conter conteúdo íntimo, de modo que os policiais quebraram o celular em seu rosto.

No mais, é de se observar que tanto os réus e testemunhas de defesa que estavam presentes na ocasião relataram em uníssono sobre a atuação policial agressiva, com ingresso na residência sem autorização e revista completa do local, nada sendo encontrado de ilícito.

Importante registrar, neste ponto, que segundo afirmado pelos réus estavam eles no interior da residência de Matheus, com ingresso dos policiais no local sem autorização, não havendo no caso em tela, aparentemente, fundado motivo para a realização da abordagem do modo como feita, implicando questionamento acerca da validade da prova, nos termos da jurisprudência, senão vejamos:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIMES DE ARMAZENAMENTO DE DROGAS E DE ARMAS. BUSCA E APREENSÃO EM APARTAMENTO NÃO HABITADO, UTILIZADO COMO LOCAL DE ARMAZENAMENTO, SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL CONCEDIDA À RESIDÊNCIA/DOMICÍLIO QUE SOMENTE ABRANGE BENS MÓVEIS OU IMÓVEIS DESTINADOS À HABITAÇÃO, AINDA QUE DE FORMA TRANSITÓRIA, E O LOCAL DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDADAS SUSPEITAS DE FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVAS NA VIA MANDAMENTAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/R0, Rel. Ministro Gilmar Mendes) DJe 8/10/2010). Nessa linha de raciocínio, o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. Precedentes desta Corte. 3. A Corte Suprema assentou, também, que "o conceito de 'casa', para o fim da proteção jurídico-constitucional a que se refere o art. 5º, XI, da Lei Fundamental, reveste-se de caráter amplo (HC 82.788/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma do STF, julgado em 12/04/2005, DJe de 02/06/2006; RE 251.445/GO, Rel. Min. CELSO DE MELLO, decisão monocrática publicada no DJ de 03/08/2000), pois compreende, na abrangência de sua designação tutelar, (a) qualquer compartimento habitado, (b) qualquer aposento ocupado de habitação coletiva e (c) qualquer compartimento privado não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade" (RHC 90.376/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma do STF, julgado em 03/04/2007, DJe de 18/05/2007). Conclui-se, portanto, que a proteção constitucional, no tocante à casa, independentemente de seu formato e localização, de se tratar de bem móvel ou imóvel, pressupõe que o indivíduo a utilize para fins de habitação, moradia, ainda que de forma transitória, pois tutela-se o bem jurídico da intimidade da vida privada. (...) (STJ - HC: 588445 SC 2020/0139280-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 25/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020).

Disto se observa que a versão dos policiais carece de maior assertividade. Com efeito, no caso sub judice, efetivamente de relevante existe apenas o alegado encontro de entorpecentes pelos policiais militares e o depoimento de tais policiais no sentido de que os réus eram quem transportava a droga. Observo, de outro giro, que nos depoimentos dos policiais estes não informaram terem visto os réus praticando efetivamente o comércio espúrio. Ainda, não há notícia de realização de campana que pudesse permitir aos policiais o acompanhamento de ações que indicassem efetiva prática de comércio de drogas pelos acusados.

Da mesma forma, não se realizou qualquer perícia dactiloscópica confirmando as digitais dos acusados na sacola ou porções que continham as drogas que supostamente teriam sido localizados em seu poder.

Frise-se, ainda, por oportuno, que sequer houve a vinda aos autos de perícia nos celulares apreendidos com um dos acusados, com conversas entre ele ou com terceiros que indicassem a venda de drogas.

Nessa esteira, em relação a controvérsia entre os depoimentos dos policiais e a versão dos réus atinente aos fatos acima analisados, é de se observar a maior robustez da prova defensiva.

A par de tudo isso, como sói ocorrer, não foi trazida qualquer outra testemunha, que estivesse presente no momento do flagrante, mesmo havendo relato de tratar-se de local supostamente conhecido como ponto de venda de droga, sendo, neste caso, pouco crível a ausência de outros usuários ou de terceiros no local, no momento do flagrante. Saliento que os próprios policiais afirmam que o local é bem conhecido como ponto de venda de drogas, havendo atuação policial no local visando combate ao tráfico de entorpecentes.

É importante salientar que em delitos de tráfico de drogas, cometidos, normalmente, na clandestinidade, a prova, em regra, é composta por depoimentos dos policiais, que de modo geral, são suficientes a demonstrar a culpabilidade de um réu, desde que em consonância com as demais provas carreadas aos autos. A presente situação não se amolda, todavia, a esta regra, lembrando que os réus negaram o tráfico de drogas, não havendo, do mesmo modo, outros indicativos seguros da ocorrência do comércio espúrio pelos acusados.

Não se trata aqui, de forma alguma, de desqualificar todo e qualquer testemunho prestado por policiais, mas de não olvidar ou ignorar o julgador a possibilidade de ocorrência de falhas perpetradas por estes no exercício de sua função, que podem até incluir imputações precipitadas, pouco apuradas, apressadas ou mesmo injustas. Ademais, experiências recentes na Comarca, inclusive na 2ª Vara, em prisões por tráfico de drogas, em situações semelhantes, com depoimentos orais análogos, nas quais surgiram dúvida sobre a dinâmica dos fatos, reforçam a necessidade de exame mais cuidadoso do conjunto probatório. Há, aliás, notícias de que o Ministério Público, em virtude de algumas irregularidades identificadas em relação a determinados testemunhos policiais (especificamente em relação aos profissionais ouvidos nos presentes autos) em processos análogos, tem envidado esforços para apurar melhor alguns episódios e condutas de agentes, conforme ofício encaminhado a este juízo. Impõe-se, portanto, uma atenção ainda maior à prova amealhada aos autos em casos como o presente.

Neste passo, transcrevo parte dos argumentos utilizados pelo magistrado sentenciante no julgamento dos autos n. 1500692-03.2022.8.26.0535:

Como regra não se deve negar credibilidade ao relato dos policiais, agentes públicos que, a priori, não possuem interesse no resultado do processo. Porém, experiências recentes na Comarca em prisões por tráfico de drogas em situações análogas, nas quais surgiram elementos objetivos colocando dúvida sobre a dinâmica dos fatos, indicam necessidade de exame mais cuidadoso das provas.

Mais do isso, são reiterados os processos penais na Comarca resultantes de atuação específica dos mesmos policiais militares aqui envolvidos ou ao menos um deles em que durante a instrução aportaram denúncias de supostos flagrantes forjados, prisões arbitrárias, agressões, ameaças, entre outras irregularidades igualmente graves.

Tais relatos não partiram apenas dos respectivos dos réus, nem de uma única ação penal, mas também de testemunhas, familiares e pessoas sem vínculos com os acusados, nas mais diversas situações, inclusive em processos que tramitam em Vara diversa. Há notícia de instauração de diversos procedimentos na Corregedoria da Polícia Militar e outras providências tomadas pelo Ministério Público a respeito dessas denúncias.

Não se está a afirmar que os policiais efetivamente praticaram aquelas irregularidades ou as sugeridas neste processo, prova dessa natureza deve ser avaliada com extrema cautela e em ambiente processual adequado. Mas sim que a

diversidade, consistência e reiteração do padrão das denúncias, sempre envolvendo os mesmos policiais, não podem ser ignoradas. Por isso, especificamente nas ações penais que apuram tráfico de drogas nesta Comarca a partir de diligências realizadas por estes policiais, excepcionalmente seus depoimentos devem receber força probatória relativa.

Em toada semelhante, manifesta-se a jurisprudência:

EMENTA: TRÁFICO DE DROGAS - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - NECESSIDADE - PALAVRA ISOLADA DOS POLICIAIS. A versão policial isolada sobre a prática do crime não forma conjunto probatório suficiente para sustentar a convicção sobre a destinação da droga apreendida e, portanto, não autoriza a condenação pelo crime de tráfico de drogas. (TJMG - Apelação Criminal 1.0699.16.010381-7/001, Relator(a): Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 27/11/2018, publicação da súmula em 03/12/2018).

Neste sentido também é o ensinamento de Gustavo Badaró:

Quanto ao testemunho dos policiais, há correntes radicais, que, pelo seu próprio extremismo, devem ser descartadas. Uma dessas correntes entende que o fato de a testemunha ser policial, por si só, não a torna impedida de depor, não havendo qualquer disposição legal neste sentido. Ao contrário, o policial não se enquadra nas hipóteses do artigo 207 do CPP, devendo ser dado ao seu depoimento o mesmo valor de qualquer outra testemunha. De outro lado, há corrente oposta, no sentido de que os policiais, pela simples condição funcional, seriam suspeitos. Deve prevalecer uma posição intermediária: se os policiais não podem ser considerados suspeitos, pelos simples fatos de serem policiais, por outro lado, é inegável o seu interesse na demonstração da legalidade de sua atuação nos atos investigatórios praticados, pelo que seus depoimentos têm valor relativo, devendo ser cotejados com outros elementos de provas existentes nos autos, em especial o testemunho de pessoas estranhas aos quadros da polícia. Não se pode esquecer que as testemunhas são, por definição, terceiros imparciais, sem qualquer interesse no processo, o que não é exatamente o caso dos policiais em relação aos crimes por ele investigados. Por tais motivos, não se deve admitir que seja proferida uma sentença condenatória com base exclusiva no depoimento de policiais, ainda que estes se demonstrem harmônicos entre si (BADARÓ, Gustavo Henrique; Processo Penal. São paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, página 477/478). (Grifos nossos)

Em sentido semelhante ao aqui exposto, esclarece, de forma muito didática, Aury Lopes Jr:

Da mesma forma, não há que se falar em restrição ao depoimento dos policiais. Eles podem depor sobre os fatos que presenciaram e ou dos quais têm conhecimento, sem qualquer impedimento. Obviamente, deverá o juiz ter muita cautela na valoração desses depoimentos, na medida em que os policiais estão naturalmente contaminados pela atuação que tiveram na repressão e apuração do fato. Além dos prejulgamentos e da imensa carga de fatores psicológicos associados à atividade desenvolvida, é evidente que o envolvimento do policial com a investigação (e prisões) gera a necessidade de justificar e legitimar os atos (e eventuais abusos) praticados. Assim, não há uma restrição ou proibição de que o policial seja ouvido como testemunha, senão que deverá o juiz ter muita cautela no momento de valorar esse depoimento. A restrição não é em relação à possibilidade de depor, mas sim ao momento de (des)valorar esse depoimento. Contudo, é recorrente o Ministério Público arrolar como testemunhas apenas os policiais que participaram da operação e da elaboração do inquérito. Busca, com isso, judicializar a palavra dos policiais para driblar a vedação de condenação "exclusivamente" (art. 155 do CPP) com base nos elementos informativos colhidos na investigação. Na continuação, deparamo-nos com sentenças condenatórias em que são utilizados os elementos do inquérito e o depoimento dos policiais em juízo.

No fundo, é um golpe de cena, um engodo, pois a condenação se deu, exclusivamente, com base nos atos da fase pré-processual e no depoimento contaminado de seus agentes, natural e profissionalmente comprometidos com o resultado por eles apontado, violando o disposto no art. 155 do CPP. Portanto, se não há impedimento para que os policiais deponham, é elementar que não se pode condenar só com base nos seus atos de investigação e na justificação que fazem em audiência.” (2019, p.462)

Aliás, na linha do que está sendo exposto, se a ideia fosse tomar como absoluta e incontestável toda e qualquer declaração prestada por testemunhas policiais no bojo do processo penal, despicienda seria a instrução probatória e até mesmo a valoração da prova colhida pelo Juiz de Direito. A presunção de inocência, princípio que informa todo o sistema processual penal, e que está prevista como garantia constitucional, também seria invariável e inevitavelmente fulminada.

Outrossim, como este juízo sempre vem asseverando, não é demais exigir do órgão acusador, a quem se impõe o ônus probandi, a reunião de outros elementos probatórios que não se limitem à mera repetição das declarações dos policiais que efetivaram a prisão do acusado, até porque, como consignado alhures, é natural que estes objetivem legitimar, até inconscientemente, sua própria atuação. Por oportuno, não se pode deixar de registrar, em crimes de natureza diversa do ora apurado, a par dos depoimentos policiais, são em regra produzidos outros elementos de prova, de origens distintas, a exemplo de testemunhos de terceiros, oitiva da vítima, com reconhecimento de pessoa e de objeto, etc, o que sem dúvida contribui para a realização de uma instrução processual mais robusta, com possibilidade de uma construção mais sólida da culpabilidade do agente.

Por um outro viés, estes mesmos policiais já dispõem, nos dias atuais, de outros instrumentos e mecanismos aptos a robustecer os motivos ensejadores da prisão e da persecução penal, conferindo às suas declarações um caráter de veracidade quase irrefutável, como já se pôde constatar em outras oportunidades, em que os policiais se valeram, inclusive, de gravações audiovisuais para registrar as abordagens, diligências e operações. Aliás, é pouco compreensível que nos dias de hoje, no estágio em que se encontra a tecnologia, haja ainda uma utilização tão tímida de aparatos e instrumentos de captação e gravação das abordagens policiais.

Pontua-se também, mais uma vez, que não foi trazida qualquer testemunha distinta dos policiais que pudesse corroborar a versão acusatória, o que certamente robusteceria a prova acusatória. Neste sentido são as palavras do eminente jurista Guilherme de Souza Nucci:

Parece-nos cauteloso que o magistrado, visualizando, em processos de apuração de crime de tráfico ilícito de entorpecentes, um rol de testemunhas de acusação formado somente por policiais, indague os mesmos a razão pela qual não se obteve nenhuma pessoa, como testemunha, estranha aos quadros da polícia. Essa verificação é essência, pois uma apreensão de drogas feita à vista de inúmeras pessoas, em local público, por exemplo, pode perfeitamente contar com o testemunho de pessoas que não sejam policiais. (NUCCI, Guilherme de Souza, Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 2009, p. 353).

Assim, cumpre indagar, ante aquilo que foi exposto, se o quanto relatado pelo policial pode, na hipótese em tela, ser considerada uma prova robusta e coerente para fins de fundamentalmente arrimar uma condenação por tráfico de drogas. No entendimento deste Juízo, não é.

Forçoso, in casu, verificar que, tendo negado os réus a propriedade ou porte da droga apreendida em juízo, e não havendo, além da declaração dos policiais, qualquer outra prova que confirme a prática de tráfico de entorpecente, deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo em favor dos acusados.

Em sentido semelhante, manifesta-se a jurisprudência:

TÓXICO - Crime de tráfico e associação para o tráfico - Quadro probatório que não traz a necessária certeza quanto à posse ou propriedade da droga apreendida -

Mercancia não comprovada - Indícios insuficientes para formar convicção nesse sentido - Réu preso em companhia de menor reconhecido e indicado como traficante - Ausência de atos seguros e concretos vinculando suas ações - Depoimento de agentes policiais - Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas - Análise que se faz em cada caso concreto - Dúvida remanescente que autoriza o decreto absolutório - Recurso provido - (TJSP, APELAÇÃO Nº: 990.09.047397-5 - COMARCA: ITAPECERICA DA SERRA APTÉ WELLINGTON DA SILVA SANTOS APDO : Ministério Público).

Assim, a despeito da probabilidade da ocorrência do tráfico de drogas e mesmo que se considere pouco crível a versão apresentada pelos réus, o conjunto probatório produzido não se mostra firme o bastante para lastrear uma condenação por tráfico de drogas pelos acusados.

Registre-se que, como frisado alhures, a versão dos réus pode não ser tão convincente, e ao menos o histórico de Jorge mostra-se inegavelmente desfavorável (fls. 53/58). Não obstante, à vista das circunstâncias apresentadas, e verificadas, como ressaltado, em processos análogos, outra solução não há que a absolvição. Destarte, nesta fase processual, encerrada a instrução, se alguma dúvida existe deverá ser interpretada em favor do réu, conforme recomenda a boa técnica processual penal.

Como é cediço, em casos de dubiedade, de provas colidentes ou de insuficiência probatória, o respeito à máxima da presunção de inocência impõe a absolvição da acusada como medida de justiça. Sobre a presunção de inocência, manifesta-se Aury Lopes Jr. (Direito Processual Penal e sua conformidade constitucional, vol I. Rio de Janeiro:Lumen Juris, 2008, p.178/19):

"...é princípio fundamental de civilidade, fruto de uma opção garantista a favor da tutela da imunidade dos inocentes, ainda que para isso tenha-se que pagar o preço da impunidade de algum culpável. Isso porque, ao corpo social, lhe basta que os culpados sejam geralmente punidos, pois o maior interesse é que todos os inocentes, sem exceção, estejam protegidos."

"Se é verdade que os cidadãos estão ameaçados pelos delitos, também o estão pelas penas arbitrárias, fazendo com que a presunção de inocência não seja apenas uma garantia de liberdade e de verdade, senão também uma garantia de segurança (ou de defesa social), enquanto segurança oferecida pelo Estado de Direito e que se expressa na confiança dos cidadãos na Justiça. É uma justiça que se oferece ao arbítrio punitivo"

Assim, mesmo que implique a absolvição de um culpado, a presunção da inocência deve ser integralmente aplicada quando nos autos não subsiste a certeza indispensável à prolação de um decreto condenatório, sendo certo que muito mais grave e deletério a um Estado Democrático de Direito do que soltar um culpado é impor a um inocente uma condenação penal e submetê-lo aos rigores e amarguras de uma pena privativa de liberdade.

A responsabilidade penal deve estar estreme de dúvidas e não pode ser atribuída a um sujeito de maneira precipitada. É preciso que as provas carreadas aos autos demonstrem de forma inequívoca que o acusado foi do crime, de maneira que seja possível lhe imputar a prática do delito, o que não ocorreu no caso em questão. Fato é que, sem a taxatividade própria do direito penal, impossível exarar decreto condenatório, até mesmo porque:

"O Direito Penal não opera com conjecturas ou probabilidades. Sem certeza total e plena da autoria e da culpabilidade, não pode o Juiz criminal proferir condenação" (Ac. un. da 5a. Câ., de 19-7-77, na Ap. n. 162.055, de Jaú, rel. GOULART SOBRINHO, ref. por Azevedo Franceschini, in Jurisprudência Penal e Processual Penal, vol. 8, pág. 313

No mais, conforme leciona o Procurador de Justiça Fernando de Almeida Pedroso (PEDROSO, Fernando de Almeida. Prova Penal, 2ª ed. Ed. Revista dos Tribunais, São

Paulo: 2004, pág. 150), membro do Ministério Público de São Paulo:

“A sentença de conteúdo condenatório exige, para sua prolação, a certeza de ter sido cometido um crime e de ser o acusado o seu autor. A menor dúvida a respeito acena para a possibilidade de inocência do réu, de sorte que a Justiça não faria jus a essa denominação se aceitasse, nessas circunstâncias, um édito condenatório, operando com uma margem de risco – mínima que seja – de condenar quem nada deva.

Quando se tem presente, salientou Malatesta, que a condenação não pode basear-se senão na certeza da culpabilidade, logo se vê que a credibilidade razoável – também mínima – da inocência, sendo destrutiva da certeza da culpabilidade, deve, necessariamente, conduzir à absolvição”.

Com efeito, uma sentença judicial condenatória deve ser embasada em elementos objetivos, contundentes e sólidos. Em verdade, para fins de condenação criminal, a intuição deste julgador não tem qualquer importância. Não basta a crença, deve haver certeza.

Novamente, colaciona-se o escólio do Procurador de Justiça Fernando de Almeida Pedroso (PEDROSO, Fernando de Almeida. Prova Penal, 2ª ed. Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo: 2004, pág. 15):

A respeito, obtempera Heleno Cláudio Fragoso que “a condenação exige certeza e não basta, sequer, a alta probabilidade, que é apenas um juízo de nossa mente em torno da existência de certa realidade”. Mesmo a íntima convicção do Juiz – pondera Sabatini –, como sentimento da certeza, sem o concurso de dados objetivos de justificação (g.n.), não é verdadeira e própria certeza (...); no lugar da certeza, em espécie tal, tem-se a simples crença.

O entendimento do nobre membro ministerial é de rara sabedoria e desmerece contestações.

Como se vê, no caso em tela, mesmo diante da suposta localização da droga em poder dos acusados, e considerando o teor dos interrogatórios, as inconsistências apontadas, e o conjunto probatório produzido, e que a prova produzida pelo órgão acusador se restringe, basicamente, aos testemunhos policiais - que são a reprodução das declarações que constam em inquérito - os elementos amealhados no curso da instrução penal não permitem concluir com segurança necessária que os réus praticavam o crime inserto no art. 33 da lei 11.343/06. Com isso, destaque-se, não se conclui pela necessária ocorrência de um flagrante forjado, mas sim, pressupõe-se que, havendo dúvida do que ocorreu na data dos fatos, deve ser aplicada a máxima mencionada, já que a dúvida milita em favor dos acusados.

Isto posto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia e ABSOLVO os réus MATHEUS DIAS MASSARO e JORGE HENRIQUE VIEIRA MILARDE, qualificados nos autos, de todas as imputações que lhe foram dirigidas, o que faço com fulcro no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Revogo as medidas cautelares fixadas aos réus.

Se for o caso, expeça-se certidão de honorários advocatícios ao(s) Defensor(es) nomeado(s) no grau previsto na tabela do convênio DPE/OAB, independentemente de requerimento ou nova determinação, assim que houver a interposição de recurso por qualquer das partes e forem apresentadas as razões ou contrarrazões recursais, conforme o caso, pelo defensor nomeado ou, na hipótese de ausência de recurso, após a certificação do trânsito em julgado.

Cautelas e comunicações de estilo.

Havendo demais bens ou valores apreendidos, excetuado o veículo acima, decorridos 90 dias do trânsito em julgado sem que o proprietário manifeste interesse na sua restituição, fica autorizada a alienação e destinação do produto ao Funad ou Funpen, conforme o caso, a destruição (reciclagem ecológica) dos bens de baixo valor ou em estado que não permita a sua venda, no caso de quantias em dinheiro, não havendo requerimento de levantamento no prazo de 90 dias, decreto a perda da

integralidade do valor, tudo conforme disposto nos artigos 118 e seguintes do Código de Processo Penal, dos artigos 516 e seguintes das NSCGJ e ainda do disposto no Manual de Bens Apreendidos do CNJ.

P.I.C.

Aruja, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA